TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Seconda Sezione Civile

(*Provvedimento ex art. 83, comma 7 lett. h) D.L. n.18/2020, convertito in legge n.27/2020*)

IL GIUDICE

- ***Il giorno 8 ottobre 2021 alle ore 9,30***
- visto l'art. 83, comma 7 lett. h) del D.L. 17 marzo 2020 n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n.27;
- visti, altresì, il decreto del Presidente del Tribunale e il decreto del Presidente di Sezione emessi in data 20 aprile 2020;
- visto il proprio provvedimento con il quale è stata disposto lo svolgimento dell'udienza mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte;
- viste le note depositate dalle parti;

visto l'*art.281 sexies c.p.c.*, pronuncia la seguente sentenza, contenente il dispositivo e la concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale ordinario di Roma, seconda sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Eugenio Gatta, ha emesso la seguente

SENTENZA

nel giudizio di primo grado iscritto al n. 77109 del R.G.A.C.C. dell'anno 2019, posto in deliberazione ex art. 281 sexies c.p.c, all'udienza del 8.10.2021 e vertente

tra

Parte_1, in persona dell'Amministratore *pro tempore*, *Parte_2* rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'Avv. Giulio Mancini e dall'Avv. Maria Berti con studio in *Pt_1* Via di Santa Costanza n. 46 ed ivi elettivamente domiciliato in virtù di procura a margine dell'atto di citazione

- attore

contro

CP_1, in persona della Sindaca in carica *pro tempore*, Avvocato *CP_2* elettivamente domiciliata negli uffici dell'Avvocatura Capitolina in *Pt_1* via del Tempio di Giove n. 21, rappresentata e difesa dall'Avv. Tiziana Di Grezia in virtù di procura generale alle liti in atti;

Controparte_3, ai sensi dell'art. 1, comma 3 D.L. 22/10/2016 n. 193 convertito in legge dalla L. 1/12/2016 n. 225 subentrata, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di *Controparte_4* società del *Controparte_5*, con sede legale in *Pt_1* via G. Grezar 14, c.f. *P.IVA_1* in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Alessandra Fortuna (*CodiceFiscale_1*) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in *Pt_1* Lungotevere della Vittoria n. 11;

- convenuti -

OGGETTO: opposizione avverso intimazione di pagamento.

CONCLUSIONI. Come da note scritte.

PREMESSO IN FATTO CHE:

Con atto di citazione ritualmente notificato il *Parte_1* in epigrafe conveniva *CP_1* e l' *Controparte_6* al fine di ottenere l'annullamento dell'avviso di pagamento n. 097 2019 90721139 21/000 (all.l) di euro 5.590,20, notificato il 7.11.2019 a

mezzo piego raccomandato n.67332472759-3 *Parte_3* *Organizzazione_1* *[…]*, agente della riscossione per la Provincia di *Pt_1* su istanza dell'ente impostore *CP_1* . - *Org_2* *Pt_1* .

L'intimazione opposta trae origine dalla cartella di pagamento numero 097 2009 03004360 82 000 di euro 3.469,67 notificata il 13.1.2010 a mezzo piego raccomandato n.67024314650-4 a cura della *Controparte_7* allora agente della riscossione per la Provincia di *Pt_1* afferente il preteso canone occupazione permanente spazi aree pubbliche, per l'anno di riferimento 2006, comprensivo delle voci di canone, sanzioni pecuniarie, interessi, ulteriori interessi per iscrizione a ruolo e spese notifica e relative a griglie e intercapedini ubicate lungo il perimetro del *Parte_1* attore.

L'attore deduceva preliminarmente che le somme in questione non risultavano dovute, per avere il Tribunale di Roma con sentenza n. 6561/2013 non appellata pubblicata il 27.03.2013 e pertanto passata in giudicato, accolto l'opposizione proposta a suo tempo dal *Parte_1* odierno attore spiegata avverso la medesima suddetta cartella numero 097 2009 03004360 82 000, dichiarando la nullità e l'inefficacia della cartella stessa, per inesistenza del sottostante diritto di credito, con condanna del *CP_8* *[…]* alla rifusione di spese al *Parte_1* istante e compensazione delle spese tra quest'ultimo ed *Controparte_9* .

In subordine rilevava l'intervenuta estinzione - per decorso del termine prescrizionale – in assenza di atti interruttivi - di qualunque diritto, pretesa od azione relativi ai canoni per occupazione suolo pubblico anno 2006 e relativi accessori essendo trascorso il termine quinquennale di cui all'art. 2948 cc.

Eccepiva, inoltre, l'assenza di qualunque diritto di *CP_1* verso il *Parte_1* istante a titolo di canone occupazione suolo pubblico atteso che il credito vantato dall'Amministrazione per occupazione suolo pubblico non ha natura impositiva, non costituendo un'entrata tributaria bensì il corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva) conseguendone che ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 46/99, la riscossione di tali entrate mediante iscrizione a ruolo è consentita solo qualora il credito risulti da un titolo avente efficacia esecutiva che nel caso in esame, non risulta sussistente, né essendovi prova che l'Amministrazione abbia conseguito uno specifico titolo per agire esecutivamente nei confronti dell'opponente

Precisava inoltre, nel merito, l'inesistenza accertata dal Tribunale di Roma con sentenza passata in giudicato n.1677/2010 - del 25.1.2010 (giudicato esterno) di intercapedini o griglie attribuibili al *Parte_1* opponente dalle quali deriverebbe occupazione suolo pubblico.

Concludeva chiedendo: *"piaccia all'ill.mo Tribunale adito - ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta - in accoglimento dei suesposti motivi tutti di*

opposizione, spiegati in via principale come subordinata -: dichiarare illegittima, nulla o comunque priva di effetto ovvero annullare l'intimazione di pagamento opposta, ovvero accertare e dichiarare comunque non dovute le somme con la stessa intimazione richieste e pretese. Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio ".

CP_1 si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva in ordine all'intimazione di pagamento impugnata e alla sottesa cartella di pagamento n. 0972019 9072113921/000, annullata con la sentenza 6561/2013 passata in giudicato (RG 10404/2010) che aveva accolto le ragioni del ricorrente e per la quale *CP_1* aveva adottato un provvedimento di discarico nei confronti del condominio Via Pisanelli 2. (all. 4)

Precisava inoltre nel suddetto giudizio era presente *Organizzazione_1* *[…]* **, che era pertanto a conoscenza del giudicato formatosi in quanto parte nel giudizio richiamato e che aveva comunque proseguito l'azione di riscossione mediante la notificazione dell'intimazione oggetto di impugnazione e**ssendo conseguentemente l'unica responsabile dell'attività circoscritta all'intimazione impugnata in questa sede.

Ritenendo doversi dichiarare la cessazione della materia del contendere con condanna alle spese di lite solo a carico della *Controparte_10*, per le motivazioni esposte così concludeva:*" Voglia l'ILL.MO Tribunale civile di Roma adito dichiarare: - La cessazione della materia del contendere con condanna alle spese solo a carico della Controparte_3. - la carenza di legittimazione passiva di CP_1 per le motivazioni suesposte Con conseguente condanna alle spese, competenze ed onorari del presente giudizio.".*

L' *Organizzazione_1* si costituiva eccependo la correttezza dell'operato dell' *Org_1* che ha provveduto alla regolare notifica in data 7.11.2019 dell'intimazione di pagamento n. 09720199072113921 (all. 1). Precisava che da come si evinceva dall'estratto di ruolo allegato (all. 2) la cartella di pagamento sottesa all'intimazione impugnata (precisamente la n. 09720090300436082), nonostante quanto deduce il *Parte_1* attore, al momento dell'emissione e della notifica dell'intimazione, risultava perfettamente attiva ed in debito, pertanto, l' *Organizzazione_1* ha provveduto a notificare un atto sulla base di un credito perfettamente attivo.

Eccepiva, inoltre, la propria carenza di legittimazione passiva dell'ente della riscossione rispetto alle eccezioni riguardanti il merito, della pretesa in quanto di competenza dell'Ente Impositore che ha effettuato l'iscrizione a ruolo, precisando che in

difetto – come nel caso di specie - di un provvedimento di sgravio disposto dall'Ente Impositore, ovvero di sospensione disposto dalla competente Autorità Giudiziaria, l'agente della riscossione è obbligato a notificare ed a portare ad esecuzione il credito affidatogli.

Eccepiva, altresì, la carenza di legittimazione passiva anche per quanto riguardava l'eccezione di prescrizione sollevata nell'atto di citazione, formulando le seguenti conclusioni: *""Piaccia all'On. Sig. Giudice di Pace adito, contrariis reiectis: - in via preliminare: accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Tribunale in favore della Organizzazione_3 ; - nel merito: rigettare ogni domanda formulata nei confronti dell' Organizzazione_1 poiché infondata in fatto e in diritto e comunque non provata; - con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio".*

All'udienza in epigrafe la causa veniva decisa ex art. 281 sexies c.p.c, sulle conclusioni riportate.

Per quanto non espressamente riportato, si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art, 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.

OSSERVA IN DIRITTO

L'opposizione è fondata e va accolta, in primo luogo e in modo assorbente, per esser intervenuto giudicato esterno sulla questione oggetto dell'odierna controversia.

Com'è noto, in base all'orientamento consolidato della Corte di legittimità (cfr. da ultima, Cassazione, ordinanza n. 11314 del 10/05/2018), la preclusione in giudizio del riesame di uno stesso punto di diritto accertato e risolto da un precedente giudicato intercorso tra le stesse parti è subordinata alla verifica dell'identità di *causa petendi* e *petitum*, laddove l'accertamento compiuto in ordine alla situazione giuridica, ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formi la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata. In tali casi, la preclusione del riesame della questione opera anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo.

Ebbene, è indubbio che nel caso in esame questo Tribunale, con la sentenza n. 6561/2013 non appellata pubblicata il 27.03.2013 ha risolto, con efficacia di giudicato tra le medesime parti, una questione costituente premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza e, al contempo, oggetto di alcune delle eccezioni sollevate anche nel presente giudizio. Infatti, in tale sentenza, l'accoglimento dell'opposizione proposta dal Parte_1 odierno opponente, è fondata

su alcune statuizioni: a) è stata accertata la mancanza di un titolo concessorio avente ad oggetto la porzione di suolo per la quale è richiesto il pagamento del corrispettivo denominato Org_4; b) tale mancanza è stata ritenuta rilevante, anzi decisiva, nel non far insorgere il diritto del Org_2 al pagamento di un corrispettivo; c) è stata accertata la positiva dimostrazione in fatto della preesistenza delle griglie alla destinazione a uso pubblico o servitù pubblica della stessa; d) è stata affermata la mancanza di prova dell'esistenza di una servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge, non essendo a tal fine rilevante il dato dell'apertura della strada al passaggio pubblico.

Tali statuizioni risolvono una *res controversa* tra le parti in entrambi i giudizi e, unitamente considerate, bastano a respingere l'odierna pretesa di CP_1, dato che anche nel presente giudizio CP_1 ritiene irrilevante il dato consistente nella mancanza della concessione, e la sufficienza della (affermata) esistenza di una servitù di uso pubblico.

Tuttavia, l'odierna opposizione dovrebbe essere accolta anche in mancanza di tale preclusione.

Ed invero, a norma dell'art. 63 del d.Lgs. 15/12/1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), i comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa. E stabilisce che il pagamento del canone può essere anche previsto per l'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge.

CP_1 interpreta tale norma affermando che la stessa autorizza l'esazione del canone in ragione dell'esistenza di una servitù di uso pubblico. Al contrario, con tutta evidenza, la norma si limita ad autorizzare il Org_2 a prevedere l'assoggettamento al Cosap non solo delle occupazioni di suolo pubblico, ma anche delle occupazioni di suolo privato, sulle quali si sia costituita una servitù di uso pubblico, costituita nelle forme di legge.

Presupposto, dunque, per la legittimità della richiesta di Org_4, di tre requisiti: a) l'esistenza di una concessione; b) la costituzione della servitù pubblica nei modi di legge;

c) la positiva previsione da parte del singolo comune interessato, con atto normativo secondario, della obbligatorietà del pagamento di tale corrispettivo.

Ebbene, nel caso delle griglie e intercapedini non ricorre nessuno dei presupposti richiesti dal legislatore nazionale per l'insorgenza dell'obbligo di pagare la Org_4.

a) Non sussiste alcuna concessione (e ciò a prescindere dal giudicato esterno). La concessione è necessariamente un provvedimento amministrativo tipizzato, riferito specificamente al titolare della stessa, che si pone come atto conclusivo di un procedimento iniziato su istanza di parte, con cui la pubblica amministrazione costituisce *ex novo* situazioni giuridiche soggettive attive in capo al destinatario, ampliandone così la sfera giuridica. Presupposto della Org_4 è dunque una domanda amministrativa che nel caso in esame manca del tutto. Non può condividersi la tesi, pur avallata dalla Corte di legittimità in alcune pronunce, della cd. concessione presunta, frutto di uno sforzo interpretativo la cui necessità è peraltro dubbia proprio con riferimento ad un comune – com'è quello di CP_1 - che si è dato un regolamento Org_4 il cui art. 14-bis prevede, in caso di occupazione abusiva di un'area demaniale in assenza di concessione, il pagamento di un'indennità pari alla Cosap maggiorata del 50% e delle sanzioni. Tale indennità, che è istituto autonomo, fondato su ben diversi presupposti di fatto. Ebbene, oggetto della domanda proposta da CP_1 con l'opposto avviso di pagamento non è tale indennizzo (che comunque non spetterebbe per l'assenza degli altri presupposti, come si dirà in seguito). L'esistenza di tale specifica previsione tuttavia consente di evidenziare l'assoluta arbitrarietà della *causa petendi* posta a base dalla amministrazione capitolina nel tutelare le proprie presunte ragioni, dato che l'esistenza di una specifica previsione di indennizzo per l'occupazione in assenza di concessione a Pt_1 capitale di tutelare le proprie presunte ragioni senza render necessaria la creazione in via interpretativa di un istituto così eccentrico come la concessione di fatto.

b) Manca, più a monte, lo stesso presupposto della previsione, da parte del Comune interessato, ossia di Pt_1 capitale, del diritto a chiedere un corrispettivo quale la Org_4 per la concessione di una servitù di passaggio. Invero, come si è visto la legge del 1997 prevede solo la facoltà dei Comuni di istituire tale Canone. Ebbene, il CP_8 oggi CP_1, non ha esercitato tale facoltà. Né può, a parere di questo giudice, condividersi sul punto l'orientamento, ancora non assurto a diritto vivente, della Corte di cassazione, che ritiene tale previsione esser rinvenibile nell'art. 16 del Regolamento Org_4.

Tale disposizione, infatti, si limita a individuare il legittimato passivo dell'obbligo di pagamento del canone nel titolare della concessione, e non autorizza, neppure con l'interpretazione più ardita, a ritenere che tale soggetto possa ricomprendere anche il cd. concessionario di fatto, ossia lo "occupante abusivo".

c) Non è stata fornita prova sufficiente dell'esistenza di una servitù pubblica costituita nei modi di legge.

Inoltre, a norma dell'art. 21 del D.Lgs. n. 46 del 1999, l'iscrizione a ruolo del credito vantato dal *CP_8* avente causa in un rapporto di diritto privato, presuppone la formazione di un idoneo "titolo avente efficacia esecutiva", che nel caso in esame non risulta essere stato formato dall'amministrazione né adottato ai sensi dell'art. 2 del r.d. 14 aprile 1910 n. 634, né ottenuto in via giudiziale, non sussistendo, a prescindere, alcun potere da parte dell'ente impositore convenuto di procedere alla riscossione del credito mediante l'inoltro al *Parte_1* in epigrafe dell'intimazione di pagamento opposta.

Quanto al provvedimento di discarico nei confronti del condominio Via Pisanelli 2" - depositato solo all'atto della costituzione in giudizio con riferimento alle voci oggetto di causa dalla difesa di *CP_1* (all. 4), si osserva che il documento è privo di data, di protocollo e di rapporti di trasmissione, non risultando comunicato al condominio istante, di cui pertanto non può quantomeno riscontrarsi la tempestiva adozione dello stesso, che, qualora accertata avrebbe consentito un esimente valutazione di responsabilità da parte dell'Amministrazione comunale.

Del pari non può condividersi l'assunto prospettato dall' *Controparte_10* *[…]* in ordine alla sostenuta correttezza dell'operato dell' *Org_1* , atteso che il presunto credito sotteso, **NON** poteva essere considerato "perfettamente attivo" al momento in cui era stata emessa e notificata l'intimazione impugnata, poiché la cartella di pagamento numero 097 2009 03004360 82 000 di euro 3.469,67 notificata il 13.1.2010 a mezzo piego raccomandato n.67024314650-4 era stata già annullata con sentenza n. 6561/2013 pubblicata il 27.03.2013 passata in giudicato, nel giudizio iscritto al n. r.g. 10404/2010 di cui era stata parte la stessa *Org_1* come *Controparte_9*

Ogni ulteriore eccezione o deduzione deve ritenersi assorbita.

Le spese di lite che seguono la soccombenza e liquidate come da dispositivo, sono poste a carico di entrambe le parti convenute.

P.Q.M.

Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede,:

a)- accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla l'avviso di pagamento n. 097 2019 90721139 21/000 (all.l) di euro 5.590,20, notificato il 7.11.2019 a mezzo piego raccomandato n.67332472759-3 afferente il presunto omesso pagamento a favore di *CP_1* del preteso canone occupazione permanente spazi aree pubbliche, per

l’anno di riferimento 2006 recato nella cartella di pagamento numero 097 2009 03004360 82 000 di euro 3.469,67 notificata il 13.1.2010 a mezzo piego raccomandato n.67024314650-4 già annullata con sentenza n. 6561/2013 pubblicata il 27.03.2013 non appellata e passata in giudicato;

b)- condanna l’Amministrazione comunale e l *Controparte_10* , in solido, per quanto esposto in parte motiva, al pagamento delle spese di lite che liquida in € 4.835,00 per compensi nonché accessori di legge, oltre spese vive contributo unificato, bollo e notifica;

Roma, 8.10.2021

IL GIUDICE

(Eugenio Gatta)

depositata telematicamente alle ore 14,40 come risultante da consolle;